

제1장 총론

제2장 소송의 주체

1. 민사소송의 이상과 이를 실현하기 위한 행동원리로 신의칙의 4가지 적용모습은? 맥 [A-1] [부, 모, 실, 남]

민사소송의 이상은 적정, 공평, 신속, 경제인바(제1조 1항), 이를 실현하기 위한 행동원리로 신의칙은(제1조 2항) ① 상대방에게 불리한 소송상태를 만들어 놓고 이를 이용하는 소송상태의 부당 형성행위, ② 당사자 일방이 과거에 일정방향의 태도를 취하여 상대방이 이를 신뢰하고 자기의 소송상의 지위를 구축하였는데, 그 신뢰를 저버리는 선행행위와 모순되는 거동, ③ 권리자의 장기간에 걸친 권리불행사에 따라 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것이라는 의무자의 정당한 기대에 따른 소권의 실효, ④ 소송외적 목적의 추구를 위해 소송상의 권능을 행사하는 소권의 남용 행위는 신의성실의 원칙에 위반되어 허용되지 아니한다(선택적 적용설).

2. 제41조 5호의 법관의 제척사유로 불복사건의 이전심급의 재판에 관여하였을 때의 의미는 [A-7] 제척이유

① 이전심급(前審)의 재판이란 하급심 재판을 의미하는데, 직접 하급심뿐만 아니라 상고심에서 간접적으로 불복의 대상이 된 제1심판결도 포함된다. ② 재판이란 종국판결뿐 아니라 중간 재판도 포함되며, ③ 관여란 최종변론, 판결의 합의·판결의 작성 등 깊이있게 관여하는 경우를 말하고, ④ 동일사건에 대한 것이어야 한다.

3. 기피(제척)신청을 받은 법원이 소송절차정지를 하지 않아도 되는 경우는 맥 [A-8a] [각, 판, 급]

기피(제척)신청이 있는 경우 법원은 기피(제척)에 관한 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다(제48조 본문). 다만 간이각하 하는 경우(제45조 1항), 종국판결을 선고하는 경우, 또는 긴급을 요하는 경우에는 예외적으로 정지하지 않고 종국판결을 선고할 수 있다(제48조 단서).

4. 기피(제척)신청을 받은 법원이 기피(제척)신청에 대한 재판이 확정되기 전에 긴급을 요하지 아니하는 절차를 속행하였는데 이후 그 기피신청에 대한 기각 또는 각하결정이 확정된 경우, 이에 대한 흠결이 치유되는지와 관련한 판례의 입장을 서술하시오. 맥 [A-8] 본안소송절차 정지에 관한 하자 치유

하자 치유를 긍정한 判例는 '본안판단'이 이루어진 후 기피신청이 '기각'된 사안이고, 하자 치유를 부정한 判例는 '본안판단'이 이루어지기 전에 기피신청이 '각하'된 사안인바, 원칙적으로 제48조에 위반한 행위는 재판의 적정, 공평을 확보하기 위한 기피제도의 취지에 비추어 위법하지만, '소송상 이익'을 침해하지 않는 경우에 한하여 소송경제를 도모하기 위하여 흠이 치유된다고 보는 判例의 입장(절충설)이 타당하다.

5. 병합된 청구의 소가를 합산한다는 제27조 1항의 예외 3가지는? 맥 [A-10] [중, 수, 부]

① 중복청구는 중복되는 범위 내에서 흡수되고, ② 1개의 청구가 다른 청구의 수단에 지나지 않을 때 그 가액은 소가에 산입하지 않으며, ③ 과실, 지연손해, 위약금, 비용 등의 부대청구도 산입하지 않는다(제27조 2항).

6. 다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어는? [A-11] 사해행위취소의 소에서의 의무이행지

判例는 사해행위취소의 소에 있어서의 의무이행지는 '취소의 대상인 법률행위의 의무이행지'가 아니라 '(취소로 인하여 형성되는 법률관계에 있어서)의 의무이행지'라고 보아야 한다면서, 부동산등기의 신청에 협조할 의무의 이행지는 성질상 등기지의 특별재판적에 관한 민사소송법 제21조에 규정된 '등기할 공무소 소재지'라고 할 것이므로, 원고가 사해행위취소의 소의 채권자라고 하더라도 사해행위취소에 따른 원상회복으로서의 소유권이전등기 말소등기 의무의 이행지는 그 등기관서 소재지라고 볼 것이지, (원고의 주소지)을/를 그 의무이행지로 볼 수는 없다고 한다.

7. 다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어는? [A-11] 사해행위취소의 소에서의 의무이행지

判例는 부동산매매계약을 사해행위로서 취소하고 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소에서 원고가 (원물반환)을/를 청구하는 경우에는 제21조에 따라 (등기할 공공기관이 있는 곳)이/가 의무이행지(제8조)가 되고, 사안과 달리 원고가 (가액반환)을/를 청구하는 경우라면 민법 제467조 2항에 따라 지참채무의 원칙상 (원고의 주소지)가 의무이행지(제8조)가 된다.

8. 소송요건은 언제를 기준으로 판단하는가? 그렇다면 관할권의 존부는 언제를 기준으로 판단하는가? 맥 [B-7]

소송요건은 '사실심 변론종결시'를 기준으로 판단한다. 그러나 관할권의 존부는 '제소시'를 기준으로 한다고 규정하고 있다(제33조). 그 외에 제소시를 기준으로 판단하는 소송요건으로는 당사자자격과(제233조·제234조·제235조) 본소의 소송요건이 있다. [관, 당, 본]

9. 소제기로 법원에 특정한 청구에 대한 재판절차가 현실적으로 존재하는 상태인 소송계속의 효과가 발생한다. 소송계속의 발생시기는? 맥 [B-26]

소송계속의 발생시기는 '소장부분 송달시'로 보는 것이 통설, 判例이다.

10. 합의관할이 유효하기 위한 요건은? 조문을 적시할 것 맥 [A-13] [임, 소, 방, 법, 소]

제1심 법원의 합의관할에 관한 합의일 것(제29조 1항), 합의의 대상인 소송을 '일정한 법률관계'로 특정할 것(제29조 2항), 합의의 방식은 서면이어야 하고, 시기는 소제기 이전에 한정하지 않는다(제29조 2항). 관할법원이 특정되어 있을 것, 특별법상 요건을 갖출 것(소송행위의 유효요건을 갖출 것)이 요구된다.

11. 관할합의가 전속적인지 부가적인지 불분명한 경우에 관한 判例의 입장은? 맥 [A-13] 합의관할 : 합의의 방식 및 시기(제29조 2항)

경합하는 법정관할법원 중 하나를 특정하는 합의는 전속적이라고 보는 것이 당사자의 의사에 부합하지만, 법정관할 외의 관할합의가 있는 경우에도 법정관할을 배제하려는 의사라고 본다

면 당사자의 소송수행의 이익을 침해할 우려가 있으므로 부가적이라고 보는 判例의 입장이 타당하다.

12. 관할합의의 효력이 특정승계인에게 미치는지 여부에 관한 판례의 입장을 논거와 함께 적시하시오. 맥 [A-13]

① 지명채권의 양도가 있는 경우 양도통지만이 있었다면 채무자는 그 통지를 받을 때까지 양도인에 대해 생긴 사유로서 대항할 수 있으므로(민법 제451조 2항) 특정승계인 중 채권승계인에게는 효력이 미치나, ② 물권의 경우 당사자가 그 내용을 자유로이 변경할 수 없고(민법 제185조), 부동산등기법상 합의를 등기할 수도 없으므로, 특정승계인 중 물권승계인에게는 효력이 미치지 않는다.

13. 변론관할이 유효하기 위한 요건은? 조문을 적시할 것 맥 [A-14] [없, 이, 항]

① 원고가 관할권 없는 제1심법원에 소를 제기하였어야 하고(제31조), ② 피고가 이의 없이 본안에 대하여 변론하였어야 하고(제30조), ③ 피고의 관할위반의 항변이 없어야 한다(제30조). 여기서 변론이란 청구이유의 유무에 관한 사실상·법률상 진술을 말하고, 법률상 진술 간주(제148조 1항)되는 경우는 포함되지 아니한다.

14. 관할위반 이송에 관한 당사자의 이송신청권에 대한 판례의 입장을 구체적으로 서술하시오. 맥 [A-16]

判例는 당사자의 관할위반에 따른 이송신청(제34조)은 단지 법원의 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없는 것이므로 법원은 이에 대해 재판을 할 필요가 없다고 하며 즉시항고(제39조)는 물론 특별항고(제449조)도 부정하는 입장인바, 다른 이송과 달리 제34조 1항에서 당사자의 이송신청권을 규정하지 않고 있으므로 이를 부정하는 것이 타당하다.

관할위반에 따른 이송	불복여부	근거
이송신청기각결정	즉시항고 불가	이송신청권이 없으므로 그에 대한 재판 불요
이송결정	즉시항고 가능	직권에 의한 재판이므로 이송신청권 유무와 무관(제39조)
이송결정에 대한 취소결정	재항고 불가	이송신청권이 없으므로 이송결정의 요구불가

15. 이송의 효과를 구체적으로 서술하시오. 관련 조문도 적시할 것 맥 [A-18] [속, 계, 부]

① 이송결정이 확정되면 비록 잘못된 이송이라도 이송을 받은 법원은 다시 반송이나 전송을 할 수 없고(제38조 : 이송재판의 구속력), ② 소송은 처음부터 이송을 받은 법원에 계속된 것으로 본다(제40조 1항 : 소송계속의 이전). 따라서 소제기에 의한 시효중단이나 기간준수의 효력은 유지된다(소급효). ③ 이송결정을 한 법원은 결정의正本(正本)을 소송기록에 붙여 이송 받은 법원에 보내야 한다(제40조 2항 : 소송기록의 송부).

16. 전속관할위반의 이송결정의 구속력에 관한 판례의 입장을 논거를 들어 서술하시오. 맥 [A-18]

소송의 지연방지라는 이송의 공익적 취지에 비추어 전속관할의 경우에도 원칙적으로 이송결정의 구속력이 미친다고 보되, 당사자의 심급이익에 비추어 상급심에는 예외적으로 구속력이 미치지 않는다고 보는 判例의 견해(상급심불구속설)가 타당하다.

17. 당사자 확정기준에 관한 판례의 입장을 구체적으로 서술하시오. 맥 [A-20] [표, 내, 사]

判例는 “당사자는 소장에 기재된 표시 및 청구의 내용과 원인사실을 합리적으로 해석하여 확정하여야 하는 것”이라고 하여 (실질적)표시설의 입장이나, 제소 전에 피고가 사망한 것을 알지 못하고 사망자를 피고로 하여 제소한 경우에는 “상속인이 처음부터 실질적인 피고이고 다만 그 표시를 잘못된 것”이라고 하여 사망자로부터 상속인으로 ‘당사자표시정정’ 하는 것을 허용하였다.

18. 다음 괄호 안에 들어갈 알맞은 단어는? 맥 [A-38] 소제기 전 당사자 사망 [대, 당, 부]

소제기 전 피고가 사망한 경우 대법원은 “사망자를 피고로 하는 소제기는 (대립당사자) 구조를 요구하는 민사소송법상 기본원칙이 무시된 부적법한 것으로서 간과판결은 (당연무효)이고, 판결에 대한 사망자인 피고의 상속인들에 의한 (항소)나 (소송수계신청)은 부적법하다”고 판시하였으며, (당연무효)인 판결이므로 (기판력)이/가 발생하지도 않는다고 하였다(재심불가).

19. 소송계속 중 당사자 사망에 따른 소송절차가 중단되기 위한 요건은? 맥 [A-40] 소송계속 중 당사자 사망

소송계속 중 당사자가 사망한 경우 당사자의 절차권을 보장하고 쌍방심문주의를 관철하기 위해 소송절차가 중단되는 것이 원칙이다(제233조 1항 전단). 소송절차가 중단되면 판결의 선고가 제외하고는 소송절차상의 일체의 소송행위를 할 수 없으며, 상속인은 수계신청으로 중단을 해소할 수 있다(제233조 1항 후단).

소송절차가 중단되기 위해서는 i) 소송계속 중 당사자가 죽은 경우이어야 하고, ii) 소송대리인이 있는 경우가 아니어야 하며(제238조 참조), iii) 상속인이 있어야 하고, iv) 소송물이 상속될 수 있는 것이어야 한다. [중, 대, 속, 물]

20. 다음 괄호안에 들어갈 알맞은 단어는? 맥 [A-40] 소송이 중단되지 않는 경우 : 소송대리인이 있는 경우

당사자가 소송대리인에게 소송위임을 한 다음 소 제기 전에 원고가 사망한 경우 判例는 “당사자가 사망하더라도 소송대리인의 소송대리권은 소멸하지 아니하므로(제95조 제1호), 당사자가 소송대리인에게 소송위임을 한 다음 소 제기 전에 사망하였는데 소송대리인이 당사자가 사망한 것을 모르고 당사자를 원고로 표시하여 소를 제기하였다면 소의 제기는 (적법)하고, 시효중단 등 소 제기의 효력은 상속인들에게 (귀속된다). 이 경우 제233조 제1항이 유추적용되어 사망한 사람의 상속인들은 (소송절차를 수계)하여야 한다”고 하였다. 즉, 소송중단규정(제233조 1항 전단)이 아니라 수계신청규정(동조 동항 후단)만 유추적용 된다.

21. 심급대리원칙에 따른 소송절차 중단과 관련하여 판례의 입장을 구체적으로 서술하시오. 맥 [A-40]

소송대리인이 있어 당사자 사망으로 인한 소송절차의 중단이 발생하지 않는다 하더라도, 심급 대리원칙상 해당 심급의 종료로 인해 소송절차는 중단된다. 判例는 ① ‘소송대리인에게 상소제기에 관한 특별수권(제90조 2항 3호)이 없다면’ 당해 심급의 판결정본이 소송대리인에게 송달된 때에 당해 소송대리인의 대리권은 소멸되므로 그 때부터 소송절차는 중단되고, ② ‘제1심 소송대리인에게 상소제기에 관한 특별수권이 있다면’ 상소제기시부터 소송절차가 중단된다는 입장이다.

22. 다음 괄호안에 들어갈 알맞은 단어는? 맥 [A-42] 당사자 사망을 간과한 판결의 효력

대법원은 “소송계속 중 어느 일방 당사자의 사망에 의한 소송절차 중단을 간과하고 변론이 종결되어 판결이 선고된 경우에는 i) 상속인과의 관계에서 (대립당사자구조)이/가 존재하고 다만 수계시까지 절차가 중단될 뿐인바, ii) 그 판결은 소송에 관여할 수 있는 적법한 수계인의 권한을 배제한 결과(쌍방심문주의 위반)가 되는 절차상 (위법)은/는 있지만 그 판결이 당연무효라 할 수는 없고, iii) 다만 그 판결은 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로 보아 대리권흡결을 이유로 상소(제424조 1항 4호) 또는 재심(제451조 1항 3호)에 의하여 그 취소를 구할 수 있을 뿐이다”라고 한다.

※ 사자상대소송 정리

	보완방법	간과한 판결의 효력
소제기 이전의 당사자 사망(소송계속전 당사자 사망 포함)	당사자 표시정정 (실질적 원·피고는 상속인)	사망한 사람을 대상으로 한 판결은 이대립당사자구조에 흠이 있어 당연무효(상소·재심 불가)
소송계속 중 당사자 사망	중단·소송수계신청 (당연승계)	쌍방심문주의에 흠이 있어 대리권흡결의 위법(제424조 1항 4호 상소·제451조 1항 3호 재심 가능) : 유효하나 위법
변론종결 후 당사자 사망	승계집행문부여신청	판결유효(상속인에 기판력미침) : 유효하고 적법

23. 당사자 능력의 개념, 의미, 판단의 기준시기는? 맥 [A-47]

‘당사자능력’이란 소송의 주체(원고·피고)가 될 수 있는 일반적인 능력을 말한다. 소의 적법요건으로서 소송요건이자 소송행위의 유효요건에 해당하며 당사자능력이 있는지는 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단한다

24. 비법인사단의 총유재산에 대한 소송수행 방법은? 조문적시할 것 맥 [A-49]

총유재산에 관한 소송은 ① 법인 아닌 사단이 그 명의로 사원총회의 결의를 거쳐 하거나(제52조) ② 민법 제276조 1항에 따라 총유물의 관리처분권은 비법인사단의 구성원 전원에게 귀속되므로 사원 전원이 당사자가 되어 고유필수적 공동소송의 형태로 할 수 있다.

25. 비법인사단의 대표기관이 사원총회 결의 없이 한 총유물의 관리처분행위의 실체법상 법률행위와 절차법상 소송행위의 효력에 대해 판례의 입장을 논거를 들어 서술하시오. 맥 [A-49]

① 判例는 비법인사단의 대표자가 사원총회 결의 없이 총유물을 관리·처분하는 실체법상 '법률 행위'(민법 제276조)는 법령상 처음부터 대표권이 없으므로, 대표자의 독자적 처분은 '확정적 무효'이고, 이에 민법 제126조의 규정이 적용될 여지도 없다고 보아 상대방이 선의였는지 여부는 문제되지 않는다는 입장이다. ② 判例는 비법인사단의 대표자가 사원총회 결의 없이 총유물을 관리·처분하는 절차법상 '소송행위'는 특별수권을 결여한 행위로서 '소송능력' 흠결을 이유로 '각하'해야 한다는 입장이다. 다만 적법한 대표자 자격이 없는 비법인 사단의 대표자가 한 소송행위는 후에 대표자 자격을 적법하게 취득한 대표자가 그 소송행위를 추인하면 행위 시에 소급하여 효력을 갖게 되고(제60조), 이러한 추인은 '상고심'에서도 할 수 있다고 한다.

26. 조합의 소송수행 간명화 방안을 논하시오. 맥 [A-49] [당, 전, 업, 업]

① 判例는 원호대상자광주목공조합은 민법상의 조합의 실체를 가지고 있으므로 당사자능력이 없다(제52조 유추적용 부정)고 하였고, ② 합유물의 관리처분권은 조합원 전원에게 합유적으로 귀속하므로 이에 관한 소송형태는 '고유필수적 공동소송'이다(민법 제272조 본문). 다만 합유물의 보존행위는 각자 할 수 있는 바 보존행위에 관한 소송은 각자 할 수 있다(민법 제272조 단서).

③ 따라서 조합의 소송수행 간명화 방안과 관련하여

㉠ 업무집행조합원을 '소송대리인'으로 선임하여 소송수행하는 방안으로 i) 단독사건(3천 초과 1억 미만)에서 법원의 허가를 얻어 변호사 아닌 업무집행조합원을 소송위임에 의한 소송대리인으로 선임하거나(규칙 제15조 2항 2호), ii) 법률상 소송대리인으로 선임(제87조, 민법 제709조)하는 방법이 있고,

㉡ 업무집행조합원을 '당사자'로 한 소송수행 방안으로 i) 합유관계에 있는 조합원들은 제65조 전문의 소송목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 '공통'되는 경우에 해당하므로 업무집행조합원을 선정당사자로 선정하거나(제53조), ii) 민사소송법 제87조가 정한 변호사대리의 원칙이나 신탁법 제6조가 정한 소송신탁의 금지 등을 회피하기 위한 탈법적인 것이 아니고, 이를 인정할 합리적인 이유와 필요(i) 권리주체인 자의 소송수행권을 포함한 포괄적 관리처분권의 수여가 있으며, ii) 소송담당자도 소송을 수행할 고유의 이익이 있는 경우가 있는 경우에는 예외적·제한적으로 명문의 규정이 없는 임의적 소송담당이 허용되는바, 判例는 '동백홍 농계'사건에서 업무집행조합원은 조합재산에 관한 소송에 관하여 조합원으로부터 임의적 소송신탁을 받아 자기 이름으로 소송을 수행하는 것이 허용된다고 하였다. [변, 신, 합, 필(수, 고)]

27. 당사자적격이란? 맥 [A-51]

'당사자적격'이란 특정한 소송사건에서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고 본안판결을 받기에 적합한 자격을 말한다(소송법상 소송수행권 = 실체법상 관리처분권). 무의미한 소송을 방지하고 민중 소송을 배제하기 위한 제도이다.

28. 이행의 소에서 당사자적격 판단에 대한 판례의 입장을 원칙과 예외로 나누어 서술하시오. 맥 [A-52]

이행의 소에서는 자기에게 이행청구권이 있음을 주장하는 자가 원고적격을 가지며, 그로부터 이행의무자로 주장된 자가 피고적격을 갖는다. 다만, 判例는 '말소등기청구'사건에서는 등기의 무의 존부를 당사자적격의 문제로 파악하는바, 말소등기의 경우 대상과 명의자인지 여부가 등기부상 명확하므로 소송경제상 등기명의자가 아닌 경우에는 당사자적격 흠결로 보아 소각하 판결을 하는 것이 타당하다.

29. 다음 괄호안에 들어갈 알맞은 단어는? 맥 [A-52]

근저당권 또는 가등기가 부기등기에 의하여 이전된 경우 ① 양도인에 대한 근저당권설정등기 또는 가등기의 말소청구는 (피고적격)이 없어 (각하)되고, 현재의 등기명의자, 즉, '양수인'인 부기 등기명의자를 상대로 해야 한다. ② 부기등기는 주등기와 일체를 이루는 것이고 주등기와 별개의 새로운 등기는 아니므로, 부기등기에 대한 말소청구는 (소의 이익)(권리보호이익)이 없어 (각하)된다. 따라서 주등기의 말소만을 구하면 된다.

30. 단체내부의 분쟁의 피고적격에 관한 판례의 입장을 논거를 들어서 서술하시오. 맥 [A-52]

判例는 '단체피고설'의 입장에서 "주주총회결의 취소와 결의무효확인판결은 '대세적 효력'이 있으므로 그와 같은 소송의 피고가 될 수 있는 자는 그 성질상 회사로 한정된다"고 한다.

31. 채권자대위소송의 법적성질에 관한 판례의 입장을 논거를 들어서 서술하시오. 맥 [A-53]

고유의 대위권 행사로 보는 견해도 있으나, 判例는 "민법 제404조의 채권자대위권은 채권자가 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 자신의 이름으로 행사할 수 있는 권리"라고 하는바, 대위소송에서 채권자가 궁극적으로 다투려 하는 소송물은 채무자의 제3채무자에 대한 권리이므로 소송물은 채무자의 권리(피대위권리)이며 따라서 채무자와 병행하여 소송수행권이 인정된 '제3자 법정소송담당'으로 보아야 한다. [공, 물]

32. 제3자가 권리관계 주체와 함께 소송수행권을 갖는 경우(5가지)와 제3자가 권리관계 주체에 갈음하여 소송수행권을 갖는 경우(5가지)를 서술하시오. 맥 [A-53] 제3자의 소송담당

(1) 제3자가 권리관계 주체와 함께 소송수행권을 갖는 경우(병행형) [질, 공, 주, 추, 대]

병행형은 제3자가 권리귀속의 주체와 함께 소송수행권을 가지는 경우이다. 예컨대 ① 채권질의 질권자(민법 제353조), ② 다른 공유자를 위하여 보존행위를 하는 공유자(민법 제265조 단서) ③ 회사대표소송의 주주(상법 제403조) ④ 채권추심명령을 받은 압류채권자(민사집행법 제227조, 제229조 2항), ⑤ 채권자대위소송을 하는 채권자(민법 제404조)(다수설)가 있다.

(2) 제3자가 권리관계 주체에 갈음하여 소송수행권을 갖는 경우(갈음형) [정, 유, 미, 상, 파]

갈음형은 제3자가 권리귀속의 주체에 갈음하여 소송수행권을 갖는 경우이다. 예컨대 ① 청리회사의 재산관계소송의 관리인(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제78조), ② 유언집행자(민법 제1101조), ③ 주한미군의 공무수행 중 불법행위로 인한 손해배상소송에서 대한민국(한미행정협정 제23조 5

항), ④ 상속재산관리인(민법 제1053조) ⑤ 파산재단소송의 파산관재인(채무자회생 및 파산에 관한 법률 제359조)이 있다.

33. 채권자 A가 채무자 B의 제3채무자 C에 대한 채권에 대하여 각각 가압류명령·추심명령·전부명령을 받아 확정된 후, B가 C에 대해 채무이행의 소를 제기한 경우의 법률관계를 서술하시오.
맥 [B-15]

(1) 가압류명령이 확정된 경우

① “일반적으로 채권에 대한 가압류가 있더라도 이는 가압류채무자(B)가 제3채무자로(C)부터 현실로 급부를 추심하는 것만을 금지하는 것이므로 가압류채무자(B)는 제3채무자(C)를 상대로 그 이행을 구하는 소송을 제기할 수 있고, 법원은 가압류가 되어 있음을 이유로 이를 배척할 수 없다”(원고전부승소).

② 다만, 가압류·가처분된 소유권이전등기청구권에 대한 이행청구의 경우 소유권이전등기를 명하는 판결(민법 제389조 2항)은 의사(의사)의 진술을 명하는 판결로서 이것이 확정되면 채무자는 일방적으로 이전등기를 신청할 수 있고 제3채무자는 이를 저지할 방법이 없게 되므로(소유권이전등기를 명하는 판결의 경우 별도의 집행단계가 존재하지 않고, 집행공탁의 공탁물은 금전에 한정되기 때문에 제3채무자는 채무를 면할 방법이 없다) ‘가압류의 해제’를 조건으로 인용하여야 한다(원고일부승소).

(2) 추심명령이 확정된 경우

추심명령이 있는 때 압류채권자는 대위절차 없이 압류채권을 추심할 수 있다(민사집행법 제229조 2항). 과거 判例는 “채권에 대한 압류 및 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 대한 이행소송을 제기할 당사자적격을 상실한다”고 판시하였으나 바뀐 判例에 따르면 ‘추심명령’은 ‘전부명령’과 달리 추심채권자에게 추심할 권능만을 부여할 뿐, 채권 자체가 이전되는 것은 아니고 채무자는 여전히 채권자로서 소송상 이익을 가지므로 명확한 법률적 근거없이 ‘당사자적격’을 박탈하는 것은 채무자의 재판청구권을 과도하게 제한할 수 있다고 한다. 따라서 추심채무자(B)의 제3채무자(C)에 대한 소제기는 적법하고 전부 인용된다. 다만 추심채무자(B)가 승소하더라도 압류 및 추심명령이 유효한 한 채무자는 실제로 채권을 추심하거나 수령할 수 없으므로 추심채권자(A)의 추심 권능이 침해되지 않으며, 오히려 채무자가 확보한 승소 판결을 통해 추심채권자가 ‘승계집행문’을 받아 더 쉽게 강제집행할 수 있게 되어 추심채권자에게도 이익이 된다.

(3) 전부명령이 확정된 경우

전부명령이 있는 때 압류된 채권은 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전된다(민사집행법 제229조 3항). 따라서 전부채권자(A)는 갈음형 제3자 소송담당이 아니어서, 전부채무자(B)의 소송수행권은 유지된다. 그리고 이행의 소는 주장자체로 원고적격을 가지기 때문에 전부채무자(B)의 제3채무자(C)에 대한 소제기는 적법하다. 다만, 전부채무자(B)의 제3채무자(C)에 대한 이행청구소송은 실체법상의 이행청구권이 상실되었으므로(집행채권이 B에게서 A로 이전됨; 권리이전효 및 변제효), 이는 본안에서 기각되어야 할 ‘본안에 관한 항변’ 사유에 해당한다.

34. 명문의 규정이 없는 임의적 소송담당이 허용되기 위한 요건은? 맥 [A-53] [변, 신, 합, 필(수, 고)]

명문의 규정이 없는 임의적 소송담당은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 민사소송법 제87조가 정한 변호사대리의 원칙이나 신탁법 제6조가 정한 소송신탁의 금지 등을 회피하기 위한 탈법적인 것이 아니고, 이를 인정할 합리적인 이유와 필요(i) 권리주체인 자의 소송수행권을 포함한 포괄적 관리 처분권의 부여가 있으며, ii) 소송담당자도 소송을 수행할 교유의 이익이 있는 경우가 있는 경우에는 예외적·제한적으로 허용될 수 있다.

35. 判例에 따를 때 채권자의 채권자 대위소송에 따른 기판력이 채무자에게 미치기 위한 요건을 논거를 들어 서술하시오. 관련 조문도 적시할 것 맥 [A-53]

判例는 통지(민법 제405조 1항), 소송고지(제77조) 등에 의해 채무자가 대위소송이 계속된 사실을 알게 된 경우에 한하여 채무자에게 기판력이 미친다는 입장이다(제218조 3항). 채무자와 제3채무자를 공평하게 대하면서도 분쟁을 1회적으로 해결할 수 있는 판례의 입장이 타당하다. [공평, 분, 해]

36. 소송능력의 개념과 효력은? 맥 [A-55]

'소송능력'은 소송의 당사자로서 유효하게 소송행위를 할 수 있는 소송상의 행위능력이며, 민법상의 행위능력에 대응되는 것이다(제51조). 소송능력은 소제기의 적법요건이자 소송행위의 유효요건으로서, 소송무능력자의 소송행위는 소송절차의 안정상 '(유동적)무효'로 한다.

37. 법정대리인의 종류와 임의대리인의 종류를 서술하시오. 관련조문을 적시할 것 맥 [A-61], [A-62]

① 소송법상 법정대리인의 종류로는 친권자 또는 후견인 등 실체법상 법정대리인(제51조), 무능력자를 대리할 법정대리인이 없거나 대리권을 행사할 수 없을 때에 법원에 의해 선임되는 소송상의 특별대리인(제62조), 법인 등의 대표자(제64조)가 있다. ② 한편 임의대리인은 수여된 대리권의 범위에 따라 개별적 대리인과 포괄적 대리인으로 나뉜다. 특히 포괄대리권을 가진 임의대리인을 소송대리인이라고 하는데, 소송대리인에는 법률상 소송대리인과 소송위임에 의한 소송대리인이 있다(제87조).

38. 심급대리원칙에 관한 근거와 판례의 입장을 논거를 들어 서술하시오. 맥 [A-61]

소송대리인과의 신뢰관계를 고려해 判例와 같이 심급의 종료시마다 본인이 소송대리인의 소송수행여부를 결정하게 하는 것이 타당하다. 따라서 '제90조 2항 3호'의 '상소의 제기'는 '상소에 대한 응소'도 포함되므로, 소송대리인의 소송대리권은 당해 심급의 판결정본 송달로 소멸한다.

39. 무권대리인의 소송행위의 추인에 대해 판례의 입장을 논거를 들어 서술하시오. 맥 [A-63]

무권대리인의 소송행위는 당사자나 정당한 대리인이 추인하면 소급하여 유효하게 된다(제60조). 추인은(사전추인을 제외하면) 시기의 제한이 없어 상급심(상고심)에서도 하급심에서 한 무권대리인의 소송행위를 추인할 수 있고 묵시적 의사표시로도 가능하다. 判例는 원칙적으로 일괄추인만 가능하다고 하나, 소송행위 중 소취하 행위만을 제외하고 나머지 소송행위를 추인함은 소송의 혼란을 일으킬 우려가 없고 소송경제상으로도 적절하여 일부추인도 예외적으로 유효하다고 한다.

40. 소송행위에서 표현대리가 인정되는지와 관련한 판례의 입장을 논거를 들어 서술하시오. 맥 [A-63]

강제집행인낙(수락)의 의사표시와 같은 소송행위에 표현대리의 성립을 긍정할 경우 상대방의 선의·악의에 따라 소송행위의 유효·무효가 좌우되어 절차의 안정을 해할 우려가 있다는 점을 고려하면 표현대리의 성립을 부정하는 判例의 태도가 타당하다.

제3장 제1심 소송절차

41. 형식적 형성의 소의 절차상 특징을 서술하시오. 맥 [B-4] [처, 불, 청]

① 실질이 비송사건이므로 처분권주의가 배제된다. ② 불이익변경금지원칙(제415조)이 적용되지 않는다. 왜냐하면 법원은 당사자의 신청에 구속되지 않고 스스로 진실하다고 인정되는 법률관계를 선택할 수 있기 때문이다. ③ 다른 형성의 소와 달리 법률관계의 요건사실(형성요건)이 결여되어 있으므로 사건의 진위불명이 있을 수 없고 증명책임이 적용되지 않는다. 따라서 법원은 요건사실의 진위불명을 이유로 청구기각판결을 하여서는 아니되고, 반드시 재판을 하여 직권에 의하여 가장 합리적으로 판단되는 권리관계를 형성하면 된다.

42. 직권조사사항의 개념과 관련한 다음 괄호안에 들어갈 알맞은 단어는? 맥 [B-5]

‘직권조사사항’이란 법원으로서 그 판단의 기초자료인 (사실과 증거)를 직권으로 (탐지)할 의무까지는 없다 하더라도, 법원에 제출된 모든 (소송자료)를 통하여 살펴보아 직권으로 추가적인 심리·조사를 통하여 그 존재 여부를 확인하여야 할 의무가 있는 사항을 말한다. 따라서 직권조사사항은 ① 당사자가 주장한 (사실)에 한하여 판단하고, ② 당사자의 (자백)에 구속되지 않으며, ③ 당사자가 제출한 (증거)에 한정하여 판단하여야 한다

43. 소송요건심리의 선순위성과 관련한 判例의 태도를 논거를 들어 서술하시오. 맥 [B-8]

각하사유와 기각사유가 경합할 때 소송요건을 판단하지 않고 청구기각의 판결을 하면 당사자의 절차권을 침해하게 된다는 점을 고려하면 소송요건심리의 선순위성을 긍정하는 판례의 입장이 타당하다.

44. 공통적인 소의 이익으로서 권리보호의 자격 5가지를 서술하시오. 맥 [B-10] 이하 [소, 금, 장, 승, 신]

권리보호의 자격이 인정되기 위해서는 i) 청구가 소구할 수 있는 구체적인 권리 또는 법률관계에 대한 것일 것, ii) 법률상·계약상의 소제기금지사유가 없을 것, iii) 특별구체절차(소제기장애사유)가 없을 것, iv) 원고가 동일청구에 대하여 승소확정의 판결을 받은 경우가 아닐 것, v) 신의칙위반의 소제기가 아닐 것이 요구된다.